

1501423-50.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO CONSTANTE DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADA COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501423-50.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501423-50.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2346305/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 22058808 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO,

10068/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2346305 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4,

10068/21/050 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

GABRIEL HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os réus Gabriel Henrique Teixeira da Silva e Caio Ricardo, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, os réus, no dia 20 de dezembro de 2021, às 17h30min, na Rua Jacobi Corso, número 2-11, bairro Parque Alto Sumaré, nesta cidade de comarca de Bauru-SP, foram flagrados, agindo de forma associada com o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

Ainda segundo a exordial, os réus nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, previamente associados e com identidade de propósitos, mantinham em depósito 24.253,60 gramas de maconha e 1.133,62 gramas de cocaína, para fins de

tráfico.

Boletim de ocorrência (fls. 54/59), auto de exibição/apreensão (fls. 78/80), laudo de constatação preliminar (fls. 60/77), laudo definitivo (fls. 165/171), laudo da balança (fls. 187/190).

Pelo crime, foram os réus Gabriel e Caio presos em flagrante.

Durante a análise formal do ato (fls. 133/136), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 183/185, foi recebida a denúncia e determinada a citação/notificação dos ora sentenciados.

Os réus foram formalmente citados (fls. 213 e 250), tendo sido ofertada resposta à acusação (fls. 254).

A decisão de fls. 262/263 manteve o recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 284/289 foi ofertada proposta de suspensão condicional do processo, apenas no tocante ao réu Renato Aparecido da Silva, outrora processado nos termos do art. 12 da Lei nº 10.826/03, a qual foi aceita. No mesmo ato processual, foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogados os sentenciados.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 303/312 pugnando, em suma, pela procedência parcial da pretensão punitiva, condenando-se os acusados pelo delito de tráfico, nos termos da exordial, e absolvendo-os da infração penal de associação, em suma, pela ausência de estabilidade e permanência. Pediu, ainda, pela exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, valorando-se os maus antecedentes e reincidência do réu Caio, e ainda a agravante do “estado pandêmico”, afastando-se a benesse prevista no art. 33, §4º da Lei Antidrogas, pela prática de atividades criminosas, com a fixação do regime inicial fechado, para ambos os sentenciados.

Já a Defensoria às fls. 319/336 pleiteou, em preliminar, pela violação do ingresso em domicílio, o que tornaria ilícitas as provas colhidas, e desembocaria na absolvição, e, no mérito, em síntese, absolvição por ausência de provas, especialmente no tocante à associação, pela inexistência das elementares da estabilidade e permanência, ou a fixação da pena-base no mínimo legal, a valoração da confissão espontânea, o afastamento da agravante do “estado pandêmico”, a aplicação da benesse do “tráfico privilegiado”, com a fixação do regime inicial aberto, substituindo-se a privativa por restritivas de direitos, com a possibilidade de eventual recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é parcialmente procedente.

De início, a preliminar de invasão ao domicílio deve ser afastada.

Com efeito, houve justa causa. Fato é que os policiais presenciaram Gabriel com volume na cintura. Depois, demonstrou nervosismo, correu para o imóvel e tentou dispensar um volume por cima do muro. Tais circunstâncias legalizam a abordagem.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. GUARDAS MUNICIPAIS. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

2. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a entrada, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, antes do ingresso dos guardas municipais na residência, foram encontradas com o acusado 80 porções de cocaína. É que, em patrulhamento de rotina, os guardas se depararam com motocicleta apontada em denúncias anônimas pela utilização na distribuição de entorpecentes. Por tal razão, deram ordem de parada, tendo o condutor empreendido fuga, que, após perseguição, caiu e derrubou um pacote plástico, contendo as porções de cocaína.

3. É assente nesta Corte Superior a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo. Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe de 12/05/2017).

Precedentes. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos guardas municipais no domicílio do réu, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

4. Em atenção aos artigos 33 e 44 do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva do acusado Bruno em 6 anos e 8 meses de reclusão, sendo ele primário e sem antecedentes, a quantidade, a natureza e a variedade das substâncias apreendidas (418 porções de cocaína, com peso líquido de 97,89g, e 175 porções de LSD, com peso líquido de 45,07g), inclusive utilizadas para exasperar a reprimenda inicial, justificam a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

Quanto a acusada Beatriz, embora estabelecida a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão, justificada a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado, em razão de sua reincidência e da quantidade, da natureza e da variedade das substâncias apreendidas (418 porções de cocaína, com peso líquido de 97,89g, e 175 porções de LSD, com peso líquido de 45,07g), inclusive utilizadas para exasperar a reprimenda inicial.

5. O montante da pena definitiva é incompatível com a substituição da prisão por penas alternativas, conforme previsão do art. 44, inciso I, do Código Penal.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 2084715 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 17/05/2022)

Superada a questão preliminar, de rigor é o exame do mérito.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 54/59), auto de exibição/apreensão (fls. 78/80), laudo de constatação preliminar (fls. 60/77), laudo definitivo (fls. 165/171) e laudo da balança (fls. 187/190).

A autoria, de outra banda, apenas quanto à traficância, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os policiais militares José Roberto Amad Jr. e Sérgio Luiz Florentino, na fase judicial (mídia SAJ), em resumo, disseram que realizavam patrulhamento de rotina, quando visualizaram o réu Gabriel saindo de uma casa, com um volume em sua cintura.

Afirmaram que ele, ao perceber a presença da viatura, demonstrou nervosismo e correu para o imóvel de onde havia saído, quando tentou dispensar tal volume, arremessando por cima do muro, mas não conseguiu. Informaram que conseguiram abordá-lo na residência. Esclareceram que, dentro da casa, encontraram o réu Caio.

Mencionaram que, em um dos quartos, acharam diversos tijolos de maconha, além de eppendorfs, alguns vazios e outros com cocaína, além de uma bacia contendo mais cocaína. Citaram que Caio disse que foi chamado por Gabriel para levar um tijolo de maconha até o bairro Pousada Nova Esperança, onde ganharia 100 reais, sendo que disse que já tinha feito esse 'serviço' outras ocasiões. Asseveraram que Gabriel, por sua vez, contou que o dono da droga era Caio, e que trabalhava para ele.

Disseram que Caio contou aos policiais que tinha um rapaz chamado Renato, morador do bairro Jardim Flórida, que guardava uma arma de fogo para Gabriel. Afirmaram que foram até o endereço do réu Renato, onde foram atendidos pela esposa dele, sendo

que ela autorizou a entrada na residência. Informaram que encontraram apenas um coldre, tendo a arma sido encontrada apenas com a indicação de Renato. Esclareceram que Renato afirmou que o acusado Gabriel e outra pessoa chamada Riquelme deixaram uma arma, calibre 38, mas logo retornaram, buscando tal revólver.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA

284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O réu Caio Ricardo sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) negou a prática dos crimes. Em síntese, disse que foi abordado por policiais na via pública, sendo que um deles afirmou que era 'foragido da justiça'. Afirmou que foi algemado e colocado na viatura. Informou que, em seguida, a viatura parou em frente a uma casa, onde permaneceu por um período. Esclareceu que viu os policiais saindo com o réu Gabriel, algemado. Mencionou que foram em outro imóvel, onde eles prenderam outra pessoa. Citou que, na delegacia, foi acusado de ser o proprietário da droga encontrada em uma dessas casas.

O sentenciado Gabriel Henrique Teixeira da Silva, em Juízo (mídia SAJ), negou o crime. Em resumo, disse que foi até o imóvel comprar droga para seu consumo.

Afirmou que deu o dinheiro para a traficante, uma mulher, sendo que, como ela não tinha troco, saiu para trocar seu dinheiro. Informou que permaneceu em frente à residência, esperando por ela, quando os policiais chegaram e lhe abordaram na frente do imóvel. Esclareceu que não sabia que havia aquela quantidade de droga no local. Mencionou que foi colocado na viatura, quando foram para a casa de Renato. Citou que somente se encontrou com Caio, na delegacia. Asseverou que não 'deu esta versão na delegacia porque ficou com medo'.

Pela prova colhida, de rigor é a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Na casa do réu Gabriel foram apreendidas drogas (cocaína e maconha).

Além disso, no local, havia eppendorfs vazios e balança de precisão.

De outro lado, não há explicação para Caio estar no local, já que, na alegação dele, nem sequer conhecia Gabriel.

Portanto, nos moldes do art. 28, §2º da Lei nº 11.343/06 também ele traficava, até porque já condenado pela mesma prática delitiva.

Por isso, sintomático o comportamento de ambos, quando afirmaram que foram abordados pelos policiais na rua.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Diversamente, a associação para o tráfico não restou delineada.

Nada demonstra que havia estruturação, isto é, estabilidade, em muito, pela ausência de divisão de funções entre os acusados.

Ademais, também não restou comprovado que na pretensa associação haveria permanência, aqui entendida como o dolo (vontade) em continuar com a vinculação, em muito, pela ausência de investigações prévias.

Por isso, a absolvição, apenas quanto à associação, é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO CONSTANTE DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADA COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Em relação aos pedidos de redução da pena-base e aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no crime de tráfico de drogas, com o consequente abrandamento do regime prisional, o presente recurso não merece conhecimento, pois o agravante não infirmou o fundamento constante da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ.

2. Quanto ao pleito absolutório, a Corte local, dentro do seu livre convencimento motivado, apontou elementos concretos que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico, sendo que o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695777 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19/10/2021)

Sob outro aspecto, os réus devem permanecer custodiados.

Com efeito, o réu Caio é portador de maus antecedentes e reincidências (fls. 98/115).

Sob outro vértice, em que pese a primariedade de Gabriel, os entorpecentes foram apreendidos na casa dele. Dentre as drogas havia cocaína e maconha, ambas em extensa quantidade, respectivamente, 24.253,60 e 1.133,62 gramas.

Portanto, a quantidade e natureza da droga apreendida denotam que a ordem pública deve ser preservada.

No sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RELEVANTE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. GRAVE MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. Tem-se por devidamente fundamentada a prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada especialmente na relevante quantidade de droga arremessada ao presídio (545 gramas de maconha e 60 comprimidos coloridos de ecstasy), além de 87 gramas de maconha e 10 comprimidos coloridos de ecstasy apreendidos pessoalmente, o que justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ, RHC 154193 / RS, RHC 154193 / RS, relator ministro Olindo Menezes, julgado em 26/10/2021)

Passo à fixação da pena.

Réu Caio Ricardo

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais (feito nº 18490-96.2009).

Por isso, a reprimenda deve ser exasperada em 1/6, perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a quantidade (24.253,60 gramas de maconha e 1.133,62 gramas de cocaína) e a natureza (cocaína), denotam que a pena deve ser exasperada em 3/5, perfazendo 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa.

Aliás, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que tais circunstâncias - quantidade e natureza - são preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela r. jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015).

Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, o acusado é portador de reincidências (feito nº 4454-19.2014, 18532-18.2014, 3010072-25.2013 e 13024-82.2013), o que deve agravar a pena em 2/3, atingindo 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 1553 (mil quinhentas e cinquenta e três) diárias.

Ainda na fase intermediária, a agravante do "estado pandêmico" deve ser afastada.

Primeiro, o crime foi elucidado após a revogação do Decreto Legislativo nº 6/2020.

Além disso, não há informações que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o acusado é reincidente.

Nem se fale que haveria bis in idem na utilização da reincidência na segunda fase e na derradeira, por que o instituto é utilizado de maneira diversa.

Na intermediária, a reincidência é fator para agravar a pena, já que sempre deve agravar a reprimenda, nos estritos termos do art. 61 “caput” do Código Penal, e, ressaltadas as hipóteses legais.

Já na última fase é pressuposto para negar o redutor previsto no art. 33, §4º da lei 11343/06, salientando-se que os requisitos lá plasmados são cumulativos.

A variação da diminuição na minorante é cotejada com fatores diversos, tais como quantidade e natureza da droga (quando não utilizados na primeira fase), as circunstâncias da ocorrência, a personalidade do acusado, ou seja, de modo geral, o próprio art. 42 da lei 11343/06.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual, na terceira fase da dosimetria, sopesou não apenas a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que os acusados se dedicariam a atividades delituosas, especialmente ao narcotráfico, motivo pelo qual não há falar em bis in idem.

2. A simples reincidência dos réus já é elemento suficiente para, por si só, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse benefício aos acusados reincidentes.

3. Se ainda não houver decorrido o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior é geradora de reincidência, independentemente de ela ser ou não pela prática do mesmo delito.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1382648 / SP, por unanimidade, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/06/2019)

Por isso, a pena atingida na segunda fase é a definitiva.

Réu Gabriel Henrique Teixeira da Silva

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a quantidade (24.253,60 gramas de maconha e 1.133,62 gramas de cocaína) e a natureza (cocaína), denotam que a pena deve ser exasperada em 3/5, atingindo 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, inviável a aplicação da agravante do “estado pandêmico”, pelos motivos acima explicitados.

Na derradeira, inaplicável a benesse do "tráfico privilegiado". Depois, a quantidade e natureza de drogas, além da apreensão de microtubos vazios e dinheiro, denotam que o tráfico já era realizado no local há algum tempo (fls. 78/80).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 500 G DE CRACK E 4,33 G DE COCAÍNA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. CONVICÇÃO ACERCA DA DEDICAÇÃO AO CRIME CALCADA NÃO APENAS NA QUANTIDADE DE DROGAS, MAS TAMBÉM NA APREENSÃO DE PETRECHOS LIGADOS AO FABRICO, EMBALO E COMÉRCIO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TESE DE QUE A DROGA NÃO PERTENCIA AO RÉU, MAS SIM AO CORRÉU. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 1208408 / SP, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018)

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial fechado para ambos os sentenciados.

Como dito, o réu Caio é portador de maus antecedentes, além de reincidente, e, além disso, a pena é superior a 8 (oito) anos de reclusão, nos moldes do art. 33, §2º "a" do Código Penal.

Já o réu Gabriel, ainda que primário, foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão.

Ademais, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Além disso, a droga estava acondicionada, o que denota que o regime mais gravoso é o único necessário e suficiente para a reprovação do crime.

No aspecto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) NÃO APLICADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO INDICATIVAS DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS.

REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias afastaram a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 não apenas em razão da expressiva quantidade de droga apreendida ? 01 porção prensada de maconha (795,95g) e 229 porções de cocaína, na forma de "crack" (111,52g) ?, mas também a partir das circunstâncias apuradas na instrução processual, notadamente em razão da existência de provas que demonstraram que o paciente praticava o tráfico de drogas de maneira reiterada, com auxílio de comparsas, inclusive com revezamento de agentes no ponto de venda de drogas, demonstrando assim sua dedicação ao comércio ilícito de entorpecentes.

2. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao escopo do habeas corpus, na medida em que demanda a revisão do conjunto probatório, o que é inviável na via eleita.

3. O regime fechado a apenado com pena inferior a 8 (oito) anos está devidamente fundamentado na existência de uma circunstância judicial negativa.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 721659 / SP, relator ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 14/06/2022)

As quantidades das penas impedem a substituição da privativa por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL e, desta feita:

ABSOLVO os réus Caio Ricardo e Gabriel Henrique Teixeira da Silva, da infração penal prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII do CPP;

CONDENO os réus, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 15 (quinze) anos, 6

(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 1553 (mil quinhentas e cinquenta e três) diárias (réu Caio) e 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa (réu Gabriel), ambos em regime inicial fechado, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Nego aos réus Caio e Ricardo os recursos em liberdade, pelos motivos acima consignados, expedindo-se os pertinentes ofícios de recomendação.

Considerando o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 78/80. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Quanto aos aparelhos celulares e entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os sentenciados a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embargos que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA